

1526159-03.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... a) condenação anterior por crime de tráfico de entorpecentes (processo nº 0056601-27.2010.8.26.0050, da 20ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para o réu em 23/10/2013 e pena julgada extinta em 14/12/2018) e b) condenação anterior por crimes de roubo e extorsão (processo nº 0089954-39.2002.8.26.0050, da 4ª Vara Criminal do Foro Central ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1526159-03.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526159-03.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2309973/2020 - 08º D.P. BRAS, 15177720 - 08º D.P. BRAS, 6099/20/108 - 08º D.P. BRAS, 2309973 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MACIEL MOURA DO COSTA e outros

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

MACIEL MOURA DO COSTA, GETÚLIO JOSÉ OLIVEIRA DOS ANJOS, LAIRTON SARMENTO BELO e FÁBIO ALEXANDRE MASSUCIO FORMICI, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, cc. o artigo 14, inciso II, e artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 2/3), no dia 13 de dezembro de 2020, por volta das 14h30, na Rua Tamandaré, 131, Liberdade, nesta cidade e comarca, agindo em concurso de pessoas caracterizado pela unidade de desígnios com terceiro indivíduo não identificado, tentaram subtrair, para proveito comum, com rompimento de obstáculo à subtração da coisa, coisa alheia móvel, consistente em fios elétricos, bens pertencentes a Jackson Xian Zhe Wang, não consumando o delito por circunstâncias alheias a suas vontades.

Narra a denúncia que, segundo o apurado, os denunciados, no dia e horário mencionados, decidiram praticar um furto. Para tanto, dirigiram-se até o local dos fatos e, valendo-se de ferramentas, arrebentaram o arame do portão da garagem e adentraram o edifício. Ato contínuo, os autores passaram a se apossar da fiação elétrica do imóvel e a colocarem os fios em uma sacola.

Segundo a exordial, ocorreu que policiais militares foram informados via COPOM acerca de um furto em andamento no local dos fatos, motivo pelo qual lá se dirigiram. Ao adentrarem, visualizaram os autores ainda no processo de remoção dos fios, com parte dos objetos já separados na sacola mencionada. Na sequência, foram todos conduzidos à delegacia.

Interrogados em sede policial, os denunciados negaram a autoria delitiva, afirmando que adentraram o local apenas com a intenção de fixar moradia, e não furtar os fios citados (fls. 13, 17, 21 e 25).

A inicial acusatória ainda dá conta de que o delito de furto só não se consumou em razão da ação dos policiais, que chegaram a tempo ao edifício e abordaram os denunciados antes que os agentes deixassem o local em poder dos objetos.

Por fim, é da exordial que o delito foi cometido durante a vigência de estado de calamidade pública, decorrente da pandemia de coronavírus (COVID-19).

Por decisão proferida aos 14 de dezembro de 2020, a prisão em flagrante dos quatro autuados foi homologada, a prisão dos indiciados MACIEL e FÁBIO foi convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, e foi concedida liberdade provisória aos indiciados LAIRTON e GETÚLIO, sendo a eles fixadas as medidas cautelares de a) comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades, bem como para eventual atualização de endereço, b) obrigação de manter(em) o endereço atualizado junto à Vara competente (informando imediatamente eventual alteração), c) proibição de ausentar(em)-se da Comarca de residência por mais de oito dias sem prévia comunicação ao Juízo e d) recolhimento domiciliar no período noturno (das 22 horas às 6 horas) e nos dias de folga, sob pena de revogação do benefício e imediato recolhimento à prisão (CPP, arts. 310, 312 e 319) (fls. 154/158).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 17 de fevereiro de 2021, ocasião em que, tendo em vista se tratar de acusação de tentativa de furto, entendendo-se que não subsistiam elementos para a manutenção dos réus no cárcere, foi concedida liberdade provisória a todos os acusados, devendo eles comparecerem a todos os atos processuais, informarem número de telefone celular (e endereço de e-mail, se o possuir), bem como se comprometerem a não mudar de endereço sem prévia comunicação ao Juízo (fls. 183/184).

Os réus MACIEL e FÁBIO foram citados (fls. 223/224 e 225/226, respectivamente) e o i. Defensor Público apresentou resposta à acusação a favor deles, requerendo, em síntese, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária dos acusados (fl. 247).

A Defensora constituída pelos acusados GETÚLIO e FÁBIO juntou procuração aos autos (fls. 250/252 e 253/255, respectivamente) e, na sequência, apresentou resposta à acusação (fls. 256/260 e 261/265 respectivamente).

Adveio comunicação acerca de nova prisão em flagrante do acusado LAIRTON (fls. 269/299).

O réu LAIRTON foi citado (fl. 307).

A Defensora constituída de GETÚLIO novamente apresentou resposta à acusação (fls. 308/312).

O réu GETÚLIO foi citado (fl. 313).

A Defensora constituída dos réus GETÚLIO e FÁBIO renunciou aos poderes anteriormente conferidos (fls. 314/315).

Por decisão datada de 27 de janeiro de 2022, foi mantido o recebimento da denúncia para os réus GETÚLIO, FÁBIO e MACIEL (fls. 344/345).

O i. Defensor Público apresentou resposta à acusação a favor de LAIRTON, requerendo, em síntese, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 355).

Por decisão datada de 18 de junho de 2022, foi mantido o recebimento da denúncia para o réu LAIRTON, ocasião em que foi designada audiência de instrução, interrogatórios, debates e julgamento para o dia 22 de novembro de 2022 às 13h00

(fl. 363).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas policiais militares e, ao final, os réus MACIEL, GETÚLIO e FABIO foram interrogados. Foi decretada a revelia do Réu ausente, LAIRTON.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais.

A douta representante do Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada parcialmente procedente, com a condenação dos quatro acusados por crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, na modalidade tentada. Sustentou o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Por sua vez, o insigne Defensor Público requereu, em suma, a absolvição dos réus, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, referente ao rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Isto porque não há nos autos prova pericial acerca de eventuais danos causados ao portão da garagem do estabelecimento. Ademais, nenhuma testemunha ouvida à luz do contraditório presenciou a forma como os agentes teriam adentrado no estabelecimento. De qualquer forma, no caso de infrações penais que deixam vestígios, como é o caso do furto mediante rompimento de obstáculo, exige o art. 158 do Código de Processo Penal, de forma imprescindível, a realização do exame de corpo de delito. Inarredável, portanto, a realização de prova pericial para que seja acolhida a qualificadora em questão, não bastando para tanto simples prova testemunhal, tampouco eventual confissão do agente. Desta feita, requer-se o afastamento da aludida qualificadora; b) a fixação de eventuais penas no mínimo legal, diante da primariedade dos réus Lairton e Getulio e das confissões espontâneas, bem como a outorga de regime prisional aberto, considerando tratar-se de hipótese em que teria ocorrido mínima lesão ao patrimônio do ofendido (tentativa de subtração de fios elétricos que foram prontamente restituídos à vítima), de modo que a opção pelo encarceramento atentaria contra o princípio da proporcionalidade, aplicando-se, para tanto, o entendimento recente do C. Supremo Tribunal Federal (HC 123533, Relator: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015; HC 135164, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/04/2019); c) a substituição da pena privativa de liberdade de Lairton e Getulio por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, pois se trata de imputação de delito que não pressupõe o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e estão presentes todos os requisitos legais; d) a aplicação da diminuição máxima em razão da tentativa, nos termos do art. 14, parágrafo único, do Código Penal, em razão do ínfimo percorrido do "iter criminis", tendo em vista que a conduta dos agentes teria sido interrompida desde o início, diante da imediata reação adotada pelos policiais militares, a ensejar a prisão em flagrante ainda no local dos fatos, sem que houvesse a efetiva subtração de qualquer bem de valor; e) o afastamento da agravante mencionada na denúncia (art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal), uma vez que o estado de calamidade decretado em virtude da pandemia em nada contribuiu ou facilitou a execução dos delitos, devendo existir nexos entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e o crime cometido, sob pena de se caracterizar responsabilidade penal objetiva, refutada por nosso ordenamento jurídico; f) a concessão aos acusados do direito de apelarem em liberdade, pois ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada parcialmente procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que os réus são seus autores.

Houve realmente a prática do crime de furto qualificado tentado, cuja materialidade restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 4/5), pelo Boletim de

Ocorrência (fls. 6/8), pelo Termo de Declarações da vítima (fl. 11), pelas fotografias de fls. 58/67, pelo Relatório Final (fls. 72/74), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida na fase policial a vítima Jackson Xian Zhe Wang narrou “que é proprietário do imóvel, palco dos fatos; soube da ocorrência de furto através da Polícia Militar então para lá deslocou e assim que entrou em seu prédio - desabitado - constatou que os furtadores arrebentaram o portão da garagem e, quando da prisão, segundo a Polícia, tentavam a subtração dos fios elétricos do edifício” (fl. 11).

Ao ser ouvida em juízo a testemunha policial militar Rinaldo Campos Repulho Júnior, relatou, em síntese, que estavam em patrulhamento quando foi irradiado possível furto em andamento em um prédio. Se depararam com o portão arrombado. O edifício estava vazio. Foram novamente acionados via Copom porque populares tinham informado indivíduos no telhado. Durante o trajeto encontraram sacolas de fios, ferramentas, alicate, comumente utilizados nessa prática. Não lembra de ter tido contato com o proprietário do prédio.

Também foi ouvida em juízo a testemunha policial militar Mateus Henrique da Silva Lemes, que narrou, em suma, que foram acionados pelo Copom de furto em andamento. Chegando ao prédio o portão da garagem estava aberto. Entraram e nas escadas encontraram sacolas. Fizeram varredura no local e assim que chegaram no terraço vizinhos informaram sobre quatro indivíduos. Era um prédio de apartamentos. O portão estava estourado. Subiram pelas escadas até o último andar e foram encontrando sacolas com fios, ferramentas. Os quatro indivíduos estavam no telhado. Os indivíduos falaram que entraram para fazer o furto de fios. Um deles se não se engana falou que estava em situação de rua. O prédio estava em construção, não tinham moradores. Levaram os quatro indivíduos para a delegacia. Não chegou a ver nenhum dos indivíduos cortando fios. Não se recorda ao certo quantos indivíduos admitiram estar furtando e quantos não admitiram.

Ao ser interrogado em juízo, o réu Maciel Moura do Costa confessou a prática delitiva, narrando que está com 40 anos de idade. Vai fazer um ano que está preso agora em 05 de dezembro de 2022. Estava em situação de rua na época desse fato. É dependente químico, já passou por clínica de recuperação. Tem família, mulher, filhos. Só tem a pedir desculpas a tudo que causou. Passou e viu, chamou os meninos para entrar, não só iam pegar os fios, mas também iam colocar famílias para morar lá.

Ao ser interrogado em juízo, o réu Getúlio José Oliveira dos Anjos confessou a prática delitiva, narrando que está com 35 anos de idade. Está preso desde 04 de maio de 2022, pegou dois anos e 4 meses no regime semiaberto. Morava na situação de rua na época desse fato. Não tem família em São Paulo. Sofreu uma decepção no relacionamento e veio tentar em São Paulo, caiu nas drogas. É músico. Realmente isso aconteceu. Tentaram tirar uns fios, chegaram a cortar alguns fios. Não chegaram a arrombar a porta do estacionamento que já estava aberta.

Ao ser interrogado em juízo, o réu Fábio Alexandre Massucio Formici confessou a prática delitiva, narrando que está preso desde 18 de setembro de 2022, flagrante de um furto no Paraíso. A audiência está marcada para a data de hoje, as 16:00 horas. Quando foi preso por este processo estava de "RA". Ficava as vezes na casa de um amigo, mas estava mais na situação de rua. Estudou até o segundo grau completo. É técnico de manutenção de computador. Começou a usar droga aos 17 anos de idade. Já tentou parar, já foi internado em clínica aos 19 ou 20 anos, mas não adiantou. Quando chegou no prédio o portão já estava aberto. Iam pegar alguns fios para vender. Chegaram a cortar alguns fios, os quatro réus juntos.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Julio Fabbrini Mirabete (Código de Processo Penal Interpretado, 8ª ed., Editora Atlas, pág. 469):

“(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento

dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos”.

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci (Manual de Processo Penal, 3ª ed., Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 411):

“A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia”.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares, colhidos em Delegacia e em juízo, foram uníssonos e merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria Pública não apresentou qualquer razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.” (RT 616/286-7).

Dessa forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais militares, não é lícito presumir que queiram prejudicar os acusados, pois agem na defesa da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

De se observar, também, que os réus foram presos em flagrante delito no próprio prédio, tendo sido surpreendidos pelos policiais militares, no local dos fatos. Deve ser afastada a qualificadora prevista no inciso I do § 4º do artigo 155 do Código Penal, consistente em rompimento de obstáculo, nos exatos termos dos requerimentos formulados por ambas as Partes em memoriais finais, tanto pelo Ministério Público como pela Defensoria Pública, uma vez que mencionada circunstância não restou demonstrada nos autos.

Com efeito, razão assiste ao insigne Defensor Público quando aduz que nenhuma testemunha ouvida à luz do contraditório presenciou a forma como os agentes teriam adentrado no estabelecimento.

Já a qualificadora prevista no inciso IV do § 4º do artigo 155 do Código Penal, consistente no concurso de duas ou mais pessoas, por sua vez, restou amplamente evidenciada pela prova oral colhida.

Da circunstância agravante de pena prevista na alínea “j” do inciso II do artigo 61 do Código Penal (ter o agente cometido o crime em ocasião de calamidade pública). Com efeito, em que pese o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, ter reconhecido a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em virtude da pandemia de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19), in casu, não restou demonstrado que os agentes tenham se aproveitado da situação para a prática do crime de furto, ausente prova de nexo de causalidade entre a pandemia e a conduta praticada pelos réus.

Vem a lume trecho de elucidativo julgado da 2ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Não se nega a situação para lá de delicada que o mundo vive, mas a agravação da pena deve ser reservada a casos concretos, nos quais o agente se vale da calamidade pública para a prática do delito, como a hipótese de desvio de verba pública destinada à saúde ou o superfaturamento de itens essenciais ao combate do vírus mortal”. (Apelação Criminal nº 1525440-21.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, Rel. Francisco Orlando, 24 de fevereiro de 2021 – grifos nossos).

No mesmo sentido: V. Acórdão do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação Criminal nº 1514467-07.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, Relator Paulo Rossi, 23 de março de 2021, e Habeas Corpus nº 629.867/SP do Colendo Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, de 1 de fevereiro de

2021.

Assim, a circunstância agravante deve ser afastada.

Consequentemente, à luz das provas colhidas, restou configurada a prática do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes, na forma tentada, nos exatos moldes do artigo 155, § 4º, inciso IV, cc. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Passo à aplicação da pena, com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Réus FÁBIO e MACIEL.

Em primeira fase, verifico que os réus FÁBIO e MACIEL, além de reincidentes, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase, ostentam outros antecedentes desabonadores. Com efeito, consoante Folha de Antecedentes (fls. 385/398) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 425/429), o réu FÁBIO ostenta: a) condenação anterior por crime de furto qualificado (processo nº 0002324-08.2017.8.26.0635, da 3ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 24/04/2017); b) condenação anterior por crime de furto qualificado tentado (processo nº 0044907-61.2010.8.26.0050, da 6ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 22/10/2012 e pena julgada prescrita em 04/09/2013); c) condenação anterior por crime de furto tentado (processo nº 0048675-24.2012.8.26.0050, da 12ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 13/03/2014 e pena julgada extinta em 03/02/2017) e d) condenação anterior por crime de furto qualificado (processo nº 0092398-25.2014.8.26.0050, da 20ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com pena julgada extinta em 03/02/2017). Por sua vez, conforme Folha de Antecedentes (fls. 409/424) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 436/440), o réu MACIEL ostenta: a) condenação anterior por crime de tráfico de entorpecentes (processo nº 0056601-27.2010.8.26.0050, da 20ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para o réu em 23/10/2013 e pena julgada extinta em 14/12/2018) e b) condenação anterior por crimes de roubo e extorsão (processo nº 0089954-39.2002.8.26.0050, da 4ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para o réu em 08/03/2004 e pena julgada extinta em 14/12/2018). Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em um sexto acima do mínimo legalmente previsto, partindo de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea e, diante da presença concomitante da agravante da reincidência (conforme fundamentação acima), efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo as penas fixadas na primeira fase.

Em terceira fase de aplicação da pena, passo à análise da causa de diminuição de pena pela tentativa, circunstância prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Os réus superaram algumas fases do iter criminis, havendo logrado êxito em adentrar o imóvel e retirar e separar alguns dos fios que pretendiam subtrair. Todavia, antes que tivessem a posse mansa e desvigiada dos bens visados, foram surpreendidos pelos policiais militares ainda no local dos fatos. Assim, tendo sido frustrada a consumação do crime em fase intermediária, não tão próxima da consumação do delito, reduzo a pena pela metade, ou seja, 1/2, culminando com o total de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 5 (cinco) dias-multa, que, ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno em definitiva.

Réus GETÚLIO e LAIRTON.

Em primeira fase, verifico que os réus GETÚLIO e LAIRTON devem ser considerados primários neste feito, de fato cometido aos 13/12/2020, conforme se infere da Folha de Antecedentes (fls. 399/404) e da Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 430/433) de GETÚLIO e da Folha de Antecedentes (fls. 405/408) e da Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 434/435) de LAIRTON. No mais, a culpabilidade dos réus não ultrapassa o normal desvalor do crime, cometido em circunstâncias que não se mostram exageradas. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, partindo de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea para ambos os réus e ainda, para o réu LAIRTON, reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa, consoante se extrai de fl. 22, nos termos do artigo 65, inciso I, do Código Penal. Todavia, deixo de reduzir suas penas abaixo do mínimo legal, por ser entendimento jurisprudencial que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nesses termos é o teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Em terceira fase de aplicação da pena, passo à análise da causa de diminuição de pena pela tentativa, circunstância prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Os réus superaram algumas fases do iter criminis, havendo logrado êxito em adentrar o imóvel e retirar e separar alguns dos fios que pretendiam subtrair. Todavia, antes que tivessem a posse mansa e desvigiada dos bens visados, foram surpreendidos pelos policiais militares ainda no local dos fatos. Assim, tendo sido frustrada a consumação do crime em fase intermediária, não tão próxima da consumação do delito, reduzo a pena pela metade, ou seja, 1/2, culminando com o total de 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 5 (cinco) dias-multa, que, ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno em definitiva.

Do regime inicial de cumprimento da pena.

Para os réus GETÚLIO e LAIRTON, o regime inicial para cumprimento da pena será o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, letra "c", do Código Penal, tendo em vista a primariedade de mencionados réus (considerada a data do fato desses autos) e a quantidade de pena aplicada.

Por sua vez, para os réus GETÚLIO e LAIRTON, o regime inicial para cumprimento da pena também será o aberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em consonância com entendimento recente do Excelso Pretório, que tem admitido que, nos casos em que o princípio da insignificância não sirva à exclusão da tipicidade material da ação delituosa, ele possa ser invocado como fator de atenuação do regime prisional, conforme se extrai de elucidativos julgados que serão colacionados.

Registre-se que não há no processo auto de exibição e apreensão dos fios que seriam objeto da subtração não consumada, assim como não há auto de avaliação da res furtiva. No mais, também não se extrai essa informação de valor dos fios das declarações da vítima colhidas na fase policial, não tendo sido a vítima ouvida em juízo. Verifica-se, ainda, que os quatro acusados estavam à época do crime em situação de moradores de rua.

Vem, assim, importante julgado:

"PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO TENTADO. REINCIDÊNCIA.

CONCURSO DE AGENTES. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo ('conglobante'), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. 3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena. 4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta à paciente" (STF, Plenário, HC nº 123.533, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 03/08/2015 - grifos nossos).

Registre-se, outrossim, que essa orientação tem sido aplicada pela Primeira Turma

do Colendo Supremo Tribunal Federal:

"PENAL. HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARA FIXAR O REGIME ABERTO. 1. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: '(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)'. 2. Não obstante a reincidência do paciente, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 4 frascos de desodorante avaliados em R\$ 31,28) justifica a aplicação do regime aberto. 3. Ordem concedida para conceder ao paciente o regime aberto" (STF, 1ª Turma, HC nº 139.503, Rel. originário Min. Marco Aurélio, Rel. para acórdão Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 12/03/2019).

De igual modo, entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. DESPROPORCIONALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, PARA FIXAR O REGIME INICIAL ABERTO. 1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos EResp n. 221.999/RS, estabeleceu a tese de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, o aplicador do direito verificar que a medida é socialmente recomendável. 2. O paciente, reincidente em crime contra o patrimônio, estava em livramento condicional e respondia a outro processo por furto, quando subtraiu uma peça de carne de supermercado. Sua inclinação para a prática de atos da mesma tipologia impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta, sob pena de fomentar a habitualidade criminosa. 3. Entretanto, de ofício, é possível abrandar o modo de cumprimento da pena com lastro em entendimento do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do HC n. 123.108/MG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. Deveras, apesar de ser socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância ao furto simples de coisa de diminuto valor, ante a contumácia do agente, a sanção privativa de liberdade deverá ser resgatada em regime inicial aberto, de modo a paralisar a incidência do art. 33, § 2º, 'c', do CP, em observância ao princípio da proporcionalidade. 4. Habeas corpus denegado. Ordem concedida de ofício para, ratificada a liminar, estabelecer o regime inicial aberto" (STJ, 6ª Turma, HC nº 474.745, Rel. Min. Rogério Schietti, julgado em 27/08/2019 - grifos nossos).

Da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos para os réus FÁBIO e MACIEL, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Com efeito, não basta o preenchimento dos requisitos objetivos para a referida substituição (quantidade de pena e não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça a pessoa). É preciso, ainda, que estejam presentes os requisitos subjetivos previstos nos incisos II e III do artigo 44 do Código Penal. Verifica-se, no caso, a presença da agravante da reincidência, sendo que, em face das condenações anteriores, a medida não é socialmente recomendável, nos termos do § 3º do citado artigo.

Por outro lado, diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade dos réus GETÚLIO e LAIRTON (à época do fato imputado nesses autos), cabível a concessão dos benefícios previstos nos artigos 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena igual a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução, com fundamento no artigo 44, § 2º, e no artigo 46, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR os acusados MACIEL MOURA DO COSTA, GETÚLIO JOSÉ OLIVEIRA DOS ANJOS, LAIRTON SARMENTO BELO e FÁBIO ALEXANDRE MASSUCIO FORMICI, qualificados nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, inciso IV, cc. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, impondo, por isso, para os réus FÁBIO e MACIEL, a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como o pagamento de 5 (cinco) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legalmente previsto, e, para os réus GETÚLIO e LAIRTON, a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, da forma anteriormente especificada, bem como o pagamento de 5 (cinco) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legalmente previsto.

As penas de multa serão calculadas por seu valor unitário mínimo, atendendo ao disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que os réus tenham condição financeira favorecida.

Tendo os réus sido beneficiados com a liberdade provisória neste processo e, ainda, considerando o regime aberto ora fixado, faculto-lhes o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea “a”, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno cada um dos réus a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, lancem-se os nomes dos réus no “Rol dos Culpados” e expeçam-se as guias de execução definitivas (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, arts. 467 e seguintes das NSCGJ), nos termos da Resolução nº 474 do CNJ.

Com o trânsito em julgado, comunique-se à Justiça Eleitoral para as providências cabíveis, em observância ao disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal e no artigo 48 da Resolução TSE nº 23.669, de 14 de dezembro de 2021.

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, certificado o trânsito em julgado da condenação, expeçam-se as certidões da sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA